

1501406-05.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Daniel Bernardes dos Reis, em juízo, afirmou que é policial militar e, no dia dos fatos, em local conhecido pelo tráfico, em patrulhamento, avistaram o réu com uma sacola e, ao ver a viatura, tentou se evadir para um descampado. O depoente correu e o abordou. Em revista pessoal encontrou 2 pinos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501406-05.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501406-05.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Pedro Rodrigues de Carvalho

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

João Pedro Rodrigues de Carvalho foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 11 de outubro de 2022, às 22 horas, na rua Francisco Faria Júnior, próximo do número 1350, Bairro Três Marias, Taubaté-SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo para fins de venda a terceiros 60 eppendorfs com maconha, além de 14 eppendorfs com crack e 129 eppendorfs com cocaína.

Afirma a denúncia que, na noite dos fatos policiais militares avistaram o réu com uma sacola nas mãos, momento em que ele empreendeu fuga, sendo detido logo à frente.

Em revista pessoal encontraram com o réu os entorpecentes acima enunciados, que os carregava tanto em seu bolso como em uma sacola, mais R\$80,00.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 57/59, procedendo-se à citação do réu levada a efeito às fls. 71, com resposta à acusação às fls. 75.

Designou-se audiência às fls. 76/77, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas, o réu foi interrogado e procedeu-se às alegações finais.

O Ministério Público postulou a condenação do réu. Afirmou que os fatos postos na denúncia foram comprovados pela oitiva dos policiais que relataram como se deu a prisão e o encontro das drogas. Aduz que a versão do réu não convence e nada há a tornar suspeita a versão dos policiais. Sustentou que as circunstâncias da prisão evidenciam o tráfico. Opinou pela fixação da pena acima do mínimo, com o reconhecimento da menoridade e aplicação do redutor, em metade, com regime inicial semiaberto, com substituição. Por fim, o perdimento do valor apreendido.

A Defesa, por sua vez, afirmou que o acusado não é traficante. Aduziu que não foi comprovada a venda dos entorpecentes e não há suporte fático para incriminar o réu, uma vez que está apenas há dois meses em Taubaté, tempo esse que não o habilitaria a traficar. Afirmou que o réu negou a propriedade das drogas na sacola e só correu por medo. Postulou, então, a desclassificação para a conduta do artigo 28, da Lei de Drogas. Subsidiariamente, entende eventualmente cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois primário e sem antecedentes, sendo que sua conduta e caráter são condizentes com o benefício. Na dosimetria, na primeira fase nenhum vetor a levar a pena acima do mínimo e a quantidade não foi significativa. Na segunda, pede o reconhecimento da menoridade relativa e, na terceira fase, a redução no patamar máximo e substituição, postulando eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de depoimento (fls. 2 e 3), termo de interrogatório (fls. 4), boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 9), auto de constatação preliminar de fls. 11/16 e laudo pericial definitivo (fls. 95/97) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Daniel Bernardes dos Reis, em juízo, afirmou que é policial militar e, no dia dos fatos, em local conhecido pelo tráfico, em patrulhamento, avistaram o réu com uma sacola e, ao ver a viatura, tentou se evadir para um descampado. O depoente correu e o abordou. Em revista pessoal encontrou 2 pinos no bolso, R\$80,00 e um celular. Com ele havia uma sacola com mais entorpecentes, sacola que se encontrava nas mãos dele. Foram até a residência apenas para avisar os familiares da prisão.

A testemunha Roger Ribeiro, em juízo, aduziu que é policial militar e, no dia dos fatos, o réu os visualizou e correu mas o perseguiram. Seu companheiro foi atrás do

rêu e o deteve, sendo que com ele estavam 2 pinos e R\$100,00, além daqueles que se encontravam na sacola. O réu afirmou que era usuário e havia começado a vender naquela noite. Aduziu que o réu escorregou e caiu, momento em que soltou a sacola.

O réu João Pedro Rodrigues de Carvalho afirmou que tem conhecimento da acusação e negou os fatos. Disse que morava com sua avó e está na cidade há 2 meses. Relatou que há uma quadra próximo de onde mora e comprou 2 pinos, pagando com R\$100,00 recebendo R\$80,00 de troco. Afirmou que um indivíduo gritou ao avistar a viatura e saiu correndo o que motivou a correr também. Negou que estava com uma sacola na mão. Tem 20 anos e mora com os pais. Veio para Taubaté com seus pais e não trabalha. Diz que usa cocaína desde criança. Estudou até o sétimo ano. Não tem passagens anteriores.

Dispõem o artigo no qual foi denunciado o réu:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Analisando os autos de forma acurada, especialmente os elementos de informação colhidos no inquérito policial, que se somam às provas produzidas sob o contraditório judicial, verifica-se que a conduta do réu se enquadra no verbo trazer consigo drogas, previsto no núcleo do tipo, para o fim de venda a terceiro, de forma que resultou configurada a traficância.

Com efeito, os policiais ouvidos afirmaram que em patrulhamento avistaram o réu que assim que avistou a viatura colocou-se em fuga e, detido, foram com ele encontradas as drogas.

Anoto que o fato de haver apenas o testemunho dos policiais a incriminar o réu, não é razão bastante para infirmar o teor dos depoimentos, ainda mais sem qualquer outro elemento de prova em sentido contrário, cabendo ser ressaltado que o réu corroborou a versão dos policiais em seu interrogatório, negando apenas que estivesse na posse da sacola com entorpecentes.

Registro que os depoimentos prestados são coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalto que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Assim, não há dúvida acerca do ocorrido, o que demanda a responsabilização do réu.

Quanto às teses expostas pela defesa técnica e em autodefesa, importa anotar que a alegação de que tinha consigo apenas 2 pinos e que seria para o consumo próprio não encontra amparo nas provas dos autos, revelando-se claramente inverossímil.

Anoto que ambos os policiais afirmaram que a sacola foi vista em poder do réu e com ele encontrada quando foi detido logo após cair durante a tentativa de se evadir, momento que teria soltado o objeto.

A propósito da versão do réu, não se mostra minimamente plausível que alguém que não tem renda, que é usuário há longos anos de cocaína e tendo consigo R\$ 100,00, que lhe teria sido dado por seu pai, compre de forma absolutamente comedida dois únicos pinos de droga, guardando para si o valor de R\$ 80,00 que sobrou.

Assim, toma-se por verdadeiras as palavras dos policiais que nenhum motivo tinham para inventar fatos que não ocorreram, muito menos para incriminar falsamente alguém que nem mesmo conheciam.

Nesse particular, registro que a alegação de que os policiais forjaram as drogas também não conta com qualquer mínimo respaldo nos elementos de prova existentes nos autos.

Com efeito, não havia motivo algum para que os policiais incriminassem o réu com drogas que não lhe pertenciam. Essa tese levantada pressuporia que os policiais seriam corruptos e que incriminariam as pessoas a seu alvedrio, o que se mostra irrazoável, ilógico.

Não se vê, nesse ponto, qualquer motivo para que os policiais agissem dessa forma. A polícia está a serviço da justiça e, com exceção de alguns poucos casos – que sempre são repreendidos de forma severa – a quase que totalidade dos policiais é honesta e não se presta a delitos. A alegação, como rotineiramente ocorre, constitui busca somente livrar o réu de sua certa responsabilidade.

O que se evidencia, mais uma vez, é uma tentativa desesperada de atribuir aos policiais, que atuam ao lado da lei, a responsabilidade que é do réu, desviado em sua conduta, valendo-se de meios ilícitos e ilegais para obter dinheiro fácil.

A alegação de que está em Taubaté há apenas dois meses, da mesma forma, não é impeditivo para que estivesse perpetrando o crime de tráfico, havendo relato de ambos os policiais que o réu teria afirmado durante a abordagem que seria o primeiro dia que estava vendendo drogas.

Nada obstante, no caso concreto se afigura cabível a aplicação do artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/06. Isso porque o réu é primário, ostenta bons antecedentes, não havendo prova que se dedique a atividades criminosas, tampouco que integre associação criminosa.

Observo, contudo, que a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu excede o que normalmente ocorre em situações semelhantes, havendo ainda grande diversidade de substâncias entorpecentes, algumas com grande poder de difusão do vício, razão pela qual entendo justificada que a redução se dê no patamar intermediário, ou seja, em metade.

Vê-se, nesse contexto, que o réu era, por ocasião dos fatos, imputável e tinha plena consciência do ilícito perpetrado, não havendo excludente de ilicitude ou de culpabilidade que viesse em seu benefício.

A prova nos autos produzida, atenta ao contraditório e à ampla defesa, é segura e não deixa dúvida de que praticou a conduta descrita na denúncia, devendo responder pelo crime em questão.

Afirmada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, atendendo-se à disposição do artigo 68, do Código Penal, ao critério trifásico proposto por Nélson Hungria e ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social da agente.

A quantidade das drogas, apesar de significativa, e a diversidade com a apreensão de drogas com alto poder de difusão do vício, não se afigura bastante a pesar em desfavor do réu nessa fase.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que o réu mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta minoração da sua responsabilidade penal, e, o que é ainda mais censurável, atribuindo a prática de crime aos policiais que o detiveram e estavam apenas realizando o seu trabalho. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte do réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade".

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das

testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaço-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por

ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

Em outro processo que teve trâmite por esta Vara (1501572-71.2021), bem concluiu o Ilustre Desembargador Zorzi Rocha:

“A pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, destacada a rubrica da personalidade desregrada do Réu o qual modificou a realidade dos fatos com o nítido intuito de minimizar os efeitos de sua conduta, dificultar a análise da prova e criar a ideia de irregularidade da conduta policial. Não se trata de mera mentira narrada em Juízo, mas da criação de realidade diversa (disse que era tatuador e tinha um estúdio de tatuagem), com a produção de prova testemunhal nesse sentido (a testemunha João Pedro disse em Juízo que foi tatuado pelo Réu, embora nunca tivesse visto seu estúdio/oficina). Destaque-se que o próprio Réu confirmou informalmente que produzia armas artesanais, fornecendo detalhes de como eram feitas a produção e a usinagem, sendo essa narrativa judicial conduta que realmente extrapolou os limites da autodefesa, podendo ser utilizada de forma regular e como aqui ocorreu para exasperação da pena-base.” (Apelação Criminal, j. em 26.5.2022).

No que respeita à culpabilidade, o que se vê é natural à espécie.

O réu é primário.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante seja para o tráfico.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, assim, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, na primeira fase, considerando a personalidade negativa do réu, elevo a pena mínima estabelecida em abstrato na fração de 1/6, e assim fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, observo a atenuante da menoridade relativa que, contudo, não pode levar a pena abaixo do mínimo, em razão do disposto no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não há circunstância agravante, tornada, assim, a pena a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da reprimenda, observo a causa de diminuição relativa ao artigo 33, §4.º, da Lei de Drogas, que importa diminuir a pena em 1/2, como acima explicitado, que assim passa a totalizar 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, impende ser ressaltado que o denominado tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 118. 533/MS). E sendo a condenação inferior a 4 anos, somada à primariedade do réu, entendo que, nesse caso, o regime imposto deve ser o aberto.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Também, excepcionalmente, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Isso porque a pena é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência, o réu não ostenta antecedentes, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição será suficiente.

Tendo em conta que a pena é superior a um ano, nos termos do artigo 44, §2.º, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em razão da substituição acima, incabível a suspensão condicional da pena, em razão do disposto no artigo 77, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, diante da quantidade de pena fixada, bem assim em razão da substituição da pena privativa de liberdade levada a efeito, a prisão cautelar não mais se justifica, impondo-se sua imediata soltura.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixa-se de cumprir o disposto no artigo 387, §2, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que ele permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes – 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido, uma vez que adveio da traficância, como resultou evidenciado nos autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho parcialmente o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu João Pedro Rodrigues de Carvalho à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, como incurso no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei nº 11.343/2006, fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, substituída por restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03. Decreto, ainda, o perdimento do dinheiro.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA